

1500973-81.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... reais para fazer o serviço de buscar dinheiro para o tráfico. Ele disse que era de Promissão. Na delegacia, ele falou que a origem do dinheiro era do tráfico. Não se recorda se o cabo Costa estava ouvindo, em razão de estar passando mal. Nunca o tinha visto antes. Sobre as porções encontradas, ele disse que era do uso pessoal dele. No depoimento dele, ele disse que ele só ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,

José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500973-81.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157000/2022 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 25466064 -

DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2157000 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR SOARES DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

1. Aos 06 de outubro de 2022, às 13:30 horas onde presente estava o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a), Senhor(a) Doutor(a) NATÁLIA BERTI foi aberta audiência designada nos autos supramencionados. conforme os termos do Comunicado 284/2020, emitido pelo E. Tribunal de Justiça, considerando a pandemia vivenciada (COVID-19).
2. Feito o pregão, verificou-se o seguinte: PRESENTE o(a) DD Promotor(a) de Justiça e Representante do Ministério Público, Senhor(a) Doutor(a) CÉSAR BOCUHY BONILHA; PRESENTES oa(s) ré(u)(s) JOÃO VITOR SOARES DA SILVA e seu/sua Defensor(a) Dr(a).MARCELO MIRANDA ROSA; PRESENTES também a(s) testemunha(s)DAYANE APARECIDA BORGES DA SILVA, GEOVANI KAYKE RIBEIRO DOS SANTOS BORGES, PAULO HENRIQUE MODONEZE COSTA, CARLOS ALBERTO ABEL PEREIRA.
3. Iniciados os trabalhos, o(a)(s) réu/ré(s) declararam expressamente que conversaram com o(a) seu/sua Defensor(a) antes da realização desta audiência, garantindo-se ainda ao(s) réu/ré(s) e a seu/sua Defensor(a) todos os meios assecuratórios da ampla defesa e contraditório. Na oportunidade, a MM Juíza advertiu a todos acerca do Comunicado 284/2020, bem como prestou maiores informações sobre a realização de videoconferência e das circunstâncias acerca da pandemia vivenciada.

Após, o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) ouviu a(s) Testemunha(s) PAULO HENRIQUE MODONEZE COSTA, CARLOS ALBERTO ABEL PEREIRA, DAYANE APARECIDA BORGES DA SILVA, GEOVANI KAYKE RIBEIRO DOS SANTOS BORGES.

Por fim, a Meritíssima Juíza realizou o Interrogatório do(a)(s) Ré(u)(s) JOÃO VITOR SOARES DA SILVA

4. Então, a Meritíssima Juíza DECLAROU FINDA A INSTRUÇÃO e concedeu a palavra à Acusação e à Defesa, nesta ordem, para a apresentação dos memoriais e alegações finais orais. O(A) DD Promotor(a) de Justiça manifestou-se oralmente e o conteúdo de sua manifestação foi gravado por meio audiovisual. Por seu turno, a Defesa também ofereceu alegações finais orais em audiência, cujo teor foi gravado para posterior reprodução.

5. Terminados os debates, a Meritíssima Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos.

JOÃO VITOR SOARES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 21h40, na Av. Bandeirantes, nesta Cidade e Comarca de José Bonifácio, JOÃO VITOR SOARES DA SILVA, qualificado a fls. 06, trazia consigo, para fins de tráfico, 1,29 (um grama, duzentos e noventa miligramas) de cocaína, divididos em 05 porções, e 14,81g (quatorze gramas, oitocentos e dez miligramas) de maconha, divididas em 02 porções, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão da droga de fls. 47, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de substância entorpecente de fls. 50/52 e Laudo Pericial Definitivo de fls. 126/128).

Conforme apurado, no dia e local dos fatos, policiais militares durante fiscalização de rotina, avistaram um veículo transitando pela contramão de direção da Rua Antônio Gonçalves da Silva, na região central da cidade, tendo realizado o acompanhamento do mesmo, e o abordado na Av. Bandeirantes, ocasião na qual identificaram que o automóvel era conduzido pelo denunciado.

Durante a abordagem policial, o denunciado dispensou duas porções de maconha ao lado da porta do motorista, que foi localizada e apreendida. Em revista pessoal, localizaram em um dos bolsos da blusa de frio do denunciado, a quantia de R\$ 4.950,00, cuja procedência não conseguiu demonstrar.

Na sequência, após ser solicitado a desbloquear seu aparelho celular, o denunciado empreendeu fuga em desabalada carreira, sendo perseguido por um policial militar, tendo no trajeto dispensado seu celular no quintal de uma residência. Após correr cerca de cinco quarteirões, o denunciado foi alcançado e imobilizado pelos policiais. Na entrada da Delegacia para a elaboração da ocorrência, o denunciado confessou, informalmente, aos policiais que vinha toda a semana a José Bonifácio pegar dinheiro do tráfico e levar para uma pessoa em Promissão/SP, e recebia a quantia de R\$ 500,00 pelo serviço.

Em revista veicular, foi encontrada cinco porções de cocaína. O celular do denunciado foi localizado e apreendido pelos policiais.

Auto de Exibição e Apreensão da droga de fls. 47, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de substância entorpecente de fls. 50/52 e Laudo Pericial Definitivo de fls. 126/128.

As circunstâncias da apreensão, o entorpecente apreendido, bem como a quantidade do dinheiro apreendido autorizam a capitulação da conduta como tráfico.

O acusado foi preso e, em audiência de fls. 74/75, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2022 (fls. 205/207).

O réu foi citado, e apresentou resposta à acusação (fls. 198/204).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público pediu pela condenação, nos termos da denúncia.

A defesa pediu a absolvição.

Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo à análise do mérito. A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), termos de depoimento (fls. 02/05), termo de interrogatório (fls. 06/07), nota de culpa (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 44/46), auto de exibição e apreensão (fl. 47), laudo pericial (fls. 50/52: 55/56; 126/128), relatório final (fls. 130/132), bem como pela prova oral produzida.

Porém, compulsando os autos, verifico que não ficou demonstrada, com absoluta certeza, a prática do delito previsto pelo artigo 33 da Lei de Drogas. O caso é de desclassificação para o artigo 28 da referida lei. Vejamos.

Paulo Henrique Modonese Costa (testemunha de acusação) disse que estava como motorista do comandante que faz a supervisão de outras viaturas. Além de supervisor, também trabalha com o patrulhamento. Durante o patrulhamento de rotina, passavam pela avenida, sentido bairro centro. Ao passar na frente da base da polícia, visualizaram, no contrafluxo (na contramão), alguns faróis. Imediatamente, aceleraram a viatura e foram até o carro. Quando chegaram próximo (1 quarteirão), o condutor percebeu que era uma viatura/carro. Ele virou à direita. Viraram e seguiram o veículo Gol. Fizeram breve acompanhamento, cerca de 800m. Na mesma avenida Bandeirantes, perto do campo de futebol, João Vitor estacionou o carro. Pararam atrás e fizeram a abordagem. Ele saiu tranquilamente do veículo, pedindo desculpas, dizendo que estava enganado e não sabia que era da contramão. Na busca pessoal, realizada pelo depoente, ele tinha uma blusa de frio. No bolso da blusa, tinha grande quantidade de dinheiro. Não encontraram nada com ele naquele primeiro momento. Ele ficou ao lado do sargento e o depoente foi ao veículo dele.

Questionado, ele disse que tinha uma porção de maconha que, ao descer do carro, jogou no chão. O parceiro estava conversando com ele e questionando a origem do dinheiro. Dentro do carro, na parte do cinzeiro, encontraram 5 porções de crack.

Sobre a maconha, tinha uma parte maior e outra fracionada. Ele disse que era usuário de maconha. Tinham vestígios de cocaína e ele disse que era usuário.

Questionado, ele disse que tinha um celular, que estava sem bateria. Viu que o celular estava sobre o banco e que tinha bateria. Começaram a conversar com ele e questioná-lo de onde ele era, qual era a origem do dinheiro. Ele falava que tinha vendido uma moto e que alguém tinha buscado a moto de Promissão e ele teria vindo buscar o dinheiro. Ele não sabia dar detalhes da transação e precisar o valor da negociação. Então, mostrou o celular para ele e pediu para destravar o celular, para ver a negociação da venda de moto. Ele tomou o celular e colocou no bolso e disse que não iria mostrar o celular. Falaram que ele seria conduzido na delegacia.

Ele começou a passar mal, ficou totalmente alterado, tirou o chinelo e pediu para se afastarem, porque estava sem ar. Pediram para ele se sentar no chão e se acalmar. Ele percebeu o momento de descuido dos policiais, ele correu. O depoente correu atrás dele, enquanto o sargento foi para a viatura. Correram por 5

quarteirões. Na rua Osvaldo Cruz, ele se escondeu em um material de construção. Visualizando-o, fez a abordagem. O sargento chegou na sequência. Ele resistiu à abordagem, sendo necessário algemá-lo. Ele foi colocado na viatura. Fizeram o percurso inverso e, enquanto ele corria, lembrava-se dele ter jogado o celular dele. Não encontraram nada no caminho, apenas a casa onde ele jogou o celular. Localizaram o celular caído na garagem. Na queda, o celular se danificou.

Conduziram-no à delegacia, junto com o dinheiro, celular e drogas. O depoente é hipertenso e teve que ir à Santa Casa, sendo necessário ir após à delegacia. Em conversa informal, ele justificou que faz o trabalho de vir a José Bonifácio, a cada 15 dias, buscar dinheiro de origem desconhecida. Ele não sabia se era dinheiro

origem de caça níquel ou de tráfico de drogas. Ele dizia não querer falar da pessoa que entregava o dinheiro, por ter receio pela sua integridade e família. As drogas eram 5 pedras de crack e 1 porção de maconha maior, sendo outra fracionada. O réu disse que toda a droga encontrada era para uso próprio. Ele disse ter usado cocaína (tinham alguns vestígios de cocaína no local). Sobre a transação da moto, o réu não sabia dizer quem era a pessoa que foi buscar a moto, não sabia o nome do comprador. Não o conhecia de outras abordagens. Para os policiais, ele declarou que, de 15 em 15 dias, ele combinava com uma pessoa, que não queria falar quem, que pagava um valor, para vir a José Bonifácio. Ele se encontrava em um cruzamento com uma pessoa para receber o dinheiro. Ele dizia que não sabia o nome das pessoas. Sobre a origem do dinheiro, ele disse que não sabia falar se o dinheiro era oriundo do tráfico ou de caça-níqueis. No momento da abordagem, ele estava muito tranquilo. Ele desceu do carro e conversou tranquilamente. Ele foi se alterando depois. A cocaína poderia fazer com que tivesse essa sudorese. Não encontraram instrumentos para uso de entorpecentes (isqueiro, cachimbo, lata, seda etc). O dinheiro estava dividido em notas de 100, 20 e 10. A maior parte eram notas grandes. Sobre o veículo, ele era de procedência lícita. Não conheciam o réu e não tinham informações sobre o envolvimento do acusado.

Carlos Alberto Abel Pereira (testemunha de acusação) declarou que participou da abordagem. Em patrulhamento pela avenida, passavam em frente ao quartel da polícia. Viram um veículo subindo na contramão da direção. De pronto, deslocaram-se para tentar abordá-lo. Na avenida bandeirantes, abordaram-no, perto do estádio de futebol. O réu desceu e fizeram a busca pessoal nele. Ele estava com uma blusa de frio e, no bolso, localizaram 4950 reais. Ele disse que o dinheiro era de uma moto de leilão, que teria sido vendido e que teria vindo à cidade para buscar o dinheiro. A princípio, disse que não tinha nada no veículo. Porém, em busca veicular, encontrou 5 porções de crack e, na rua, uma porção de maconha. Indagado, ele começou a ficar nervoso e, logo em seguida, o réu saiu correndo. Pegou a viatura e conduziu-a na direção dele. O cabo Costa conseguiu segurá-lo. Retornando o caminho, encontraram um celular que ele teria jogado na residência. Ele foi conduzido à delegacia. Dentro do cinzeiro do veículo, havia 5 pedras de crack e uma porção de maconha. João Vitor, aparentemente, não parecia estar sob o efeito de drogas. Porém, depois, ele começou a transpirar muito. Ele disse que era usuário de droga. Não se recorda se foram encontrados instrumentos para uso, mas acredita que não. Depois que efetuaram a prisão, o cabo Costa estava passando mal. Ele foi socorrido até o hospital. Dentro da delegacia, ele mencionou que, toda semana, ele buscava dinheiro, ganhando 500 reais para fazer o serviço de buscar dinheiro para o tráfico. Ele disse que era de Promissão. Na delegacia, ele falou que a origem do dinheiro era do tráfico. Não se recorda se o cabo Costa estava ouvindo, em razão de estar passando mal. Nunca o tinha visto antes. Sobre as porções encontradas, ele disse que era do uso pessoal dele. No depoimento dele, ele disse que ele só veio buscar o dinheiro de tráfico para terceira pessoa. Ele não chegou a confirmar que ele traficava ou vendia drogas, mas apenas que buscava o dinheiro do tráfico para entregá-lo. Ele disse que era cabelereiro em Promissão.

Dayane Aparecida Borges da Silva (testemunha de defesa) disse que é amiga da esposa do réu. João Vitor é barbeiro. Nunca viu, mas a esposa dele já relatou que ele é usuário. Não tem conhecimento se ele tem moto, casa, apenas um carrinho. A esposa disse que ele usa maconha, cocaína. Não falou sobre uso de anfetamina, mas acha que ele usa crack. Ela falou que ele já esteve preso, mas não sabe o motivo.

Geovani Kayke Ribeiro dos Santos Borges (informante) disse que é amigo próximo e conhece João Vitor desde que ele saiu da cadeia. Ele trabalha com o depoente na barbearia. A barbearia é alugada no nome da mãe dele. Ele tem um gol. Ele é usuário de drogas, inclusive já usou do seu lado. Não sabe se ele exercia outra atividade. Ele é usuário de maconha e cocaína. Já o viu usando as drogas, inclusive cocaína, na forma de crack. Ele usa apenas algumas vezes. Ele ia todos os dias à barbearia e ficava trabalhando durante todo o horário do expediente.

João Vitor Soares da Silva (réu) disse que tem 28 anos. É amasiado. Tem filhos menores de idade, de 05 e 08 anos. Tem uma barbearia em sociedade com Geovani, em Promissão. Tem renda média de 1800 reais. Estudou até a 8ª série. Disse que estava

em uma rua, mas não sabe o nome, porque não é da cidade. Entrou na rua sem saber que era contramão. Foi tentar encostar em outra rua e a viatura deu sinal de parada. Parou o veículo, sem reação. Desceu do carro e fez o procedimento, permitindo a averiguação. A maconha que estava no seu colo, caiu do lado da porta do motorista. O próprio depoente indicou a maconha aos policiais. Durante a abordagem, foram feitas perguntas. Ficou nervoso, porque já tinha consumido a droga, que é derivado do mesclado, feito com maconha e crack como forma de cigarro. Não é usado cachimbo. Eles deram voz de prisão e ficou assustado, saindo correndo. Depois, parou e se rendeu. Não estava fazendo nada ilícito. Foi conduzido para o DP. Não disse que veio trazer dinheiro do tráfico. As substâncias (crack e maconha) eram do depoente, para seu consumo. Já tinha as substâncias, desde Promissão. Já tinha efetuado o uso de parte da droga, feito dois baseados. É usuário desde 17 anos. Faz uso de crack, maconha e cocaína. No dia, tinha usado crack e maconha (mesclado). Em relação ao dinheiro, tinha 4950 reais. Na cidade em que mora, o depoente tem uma barbearia e o pai também tem um bar. Dentro do bar, frequentam várias pessoas. Conheceu um rapaz, que passava dinheiro de máquina caça níquel e pedia para buscar o dinheiro, pagando-lhe o valor de 300/400 reais. Foi em Bonifácio por 3 vezes, porque estava precisando de dinheiro, a esposa estava desempregada. Concordeu em buscar o dinheiro. A abordagem era a terceira vez. A pessoa disse que a origem do dinheiro era de cigarro e caça níqueis. Já viu o rapaz no bar do seu pessoal por diversas vezes. Não comercializava entorpecentes. Já tinha sido preso por tráfico. Saiu da prisão em 2021, depois do meio do ano. Não conhecia o sargento que prestou o depoimento. Nunca foi abordado na cidade. Envolveu-se com esse transporte do dinheiro, em razão de dificuldades financeiras, porque paga aluguel do trabalho, da casa e tem despesas com alimentação. No celular, tinham fotos íntimas da sua esposa e foi o único motivo de ter se recusado a abrir. Para uso do mesclado, é preparado a maconha e o crack, fazendo um cigarro. Já tinha essa substância para consumo do dia. Um amigo do salão arrumou a droga, pois já usava frequentemente. A droga veio com o depoente, porque ela já estava dentro do carro, no cinzeiro. Queria usar a droga dentro do veículo mesmo. Não tem habilitação para dirigir. A porção de maconha estava aberta, por já ter consumido a droga. Não leu o depoimento antes de assinar, porque estava assustado. Não estava acompanhado de advogado ou familiar naquele dia. Pois bem. Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos não são suficientes para fundamentar uma condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11343/06.

Na fase extrajudicial, o réu declarou que: "O interrogando é cabelereiro, mas para complementar sua renda trabalha como "mula" e leva dinheiro para algumas pessoas. Ele trabalha com uma pessoa na cidade de Promissão que prefere não falar o nome pois tem medo. Essa pessoa contrata o interrogando para ir até o local e pegar o dinheiro. Não sabe informar se o dinheiro é do tráfico. Acredita que pode ser de compra de cigarros, máquina caça níquel ou outros ilícitos, Ele tem o costume de vir para a cidade de José Bonifácio uma vez por semana ou a cada quinze dias para pegar o dinheiro. E (...) como de costume veio até a cidade de José Bonifácio e chegou por volta de 20 horas. Pegou a quantia RS4950,00 conforme combinou com a pessoa de Promissão. Quando estava indo embora para Promissão, entrou em uma rua contra mão e foi abordado pelos policiais militares. No momento em que desceu do carro e foi abordado, ficou assustado e tentou fugir dos policiais, mas depois desistiu de fugir e se entregou. Disse que a droga apreendida com ele é para uso próprio e já veio com ela de Promissão. Ele vem usando no caminho. Quanto ao carro usado pelo interrogando, é financiado. Ele não tem habilitação para conduzir veículo automotor. O interrogando nega ter envolvimento com o tráfico de droga e disse que a droga encontrada com ele é para uso próprio" (fl. 06).

Ouvido em juízo, o réu negou, novamente, a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Reafirmou que possuía a substância entorpecente para uso próprio. Por sua vez, os policiais militares, sob o crivo do contraditório e com o compromisso de dizer a verdade, informaram que estavam em patrulhamento e avistaram um veículo na contramão, optando pela abordagem. Ao avistar a viatura, o veículo tentou fugir. Em um dado momento, o réu desceu do veículo e disse que havia se

equivocado ao entrar na contramão, por não morar na cidade. Durante busca pessoal realizada em João Vitor, no bolso da blusa, foi encontrada a quantia de R\$ 4.950,00.

Nesse momento, o réu declarou que tinha jogado certa quantidade de maconha no chão, quando desceu do veículo. A droga foi localizada na rua, sendo que parte dela estava fragmentada. Em seguida, no veículo, foram encontradas 5 porções de crack e um aparelho celular. Questionado sobre a origem do dinheiro, o réu disse que era oriundo de uma venda de uma moto, mas não soube apresentar detalhes da transação. Sobre o celular, ao ser solicitado o acesso, o réu iniciou fuga, resistindo à abordagem. Durante a fuga, o acusado arremessou o celular por cima de uma casa. Posteriormente, na frente da delegacia, o acusado declarou que vinha toda semana para José Bonifácio para buscar dinheiro do tráfico, recebendo a quantia de R\$ 500,00 pelo trabalho.

No caso, em que pese a manifestação dos policiais militares, inexistente prova segura da finalidade de mercancia ilícita. Ora, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, para a distinção do ilícito de tráfico e de uso de entorpecentes, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes dos agentes.

No caso, a versão do acusado não pode ser plenamente afastada pelo teor das provas produzidas. O réu, na Delegacia e em juízo, afirmou que é usuário de drogas e que adquiriu as substâncias entorpecentes com a finalidade de utilizá-las. Disse, inclusive, que faz uso do mesclado (mistura de crack e de maconha) e que já teria feito uso naquela data. As circunstâncias fáticas indicam que a versão do réu não está totalmente destituída de verossimilhança, pois não há elementos seguros a indicar que o acusado trazia as drogas para vendê-las.

De fato, em juízo, nenhum dos policiais afirmou ter visto o acusado em efetivo ato de mercancia. É certo que tal fato não leva à desclassificação, até mesmo porque o tipo penal comporta vários verbos núcleo do tipo (no caso, trazer consigo a droga com a finalidade de venda). No entanto, é preciso que o tráfico seja comprovado por outros elementos dos autos. E, in casu, inexistente prova segura da finalidade de venda.

Isto porque, os policiais militares não conheciam o réu e não mencionaram a existência de denúncias ou informações sobre o seu envolvimento com a prática espúria. Não se pode considerar, aqui, apenas e tão somente, a existência de condenação anterior pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Não bastasse isso, não ficou plenamente comprovado que o dinheiro transportado era oriundo do comércio ilícito e que pertencia ao acusado.

Embora os interrogatórios do réu, durante o inquérito policial e a fase judicial, possuam contradições relevantes, fato é que, em nenhum momento, o réu afirmou que transportava dinheiro oriundo de tráfico. Na delegacia, declarou que não sabia informar a origem do dinheiro, que poderia ser da compra de cigarros, máquina caça níquel ou outros ilícitos, versão novamente trazida no curso da instrução processual. No mesmo sentido, inclusive, é o depoimento do policial militar Paulo Henrique Modoneze Costa. Apesar de o policial Carlos Alberto Abel Pereira declarar que, informalmente, o réu tenha afirmado que o dinheiro era oriundo do tráfico, a versão em sentido divergente de outro agente público é suficiente para levantar a dúvida fundada sobre a comercialização ilícita.

Aliás, nesse ponto, ressalto que o transporte de dinheiro oriundo do tráfico não configuraria, por si só e de forma isolada, o tipo penal do artigo 33, da Lei de drogas, o qual estabelece, como verbos nucleares do tipo, as condutas de: portar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Era necessário demonstrar que aquelas substâncias entorpecentes se destinavam a venda, o que não aconteceu.

Com efeito, não se pretende questionar o valor do testemunho dos policiais militares. Entretanto, a prova coligida não foi suficiente a comprovar a

participação do denunciado no tráfico de drogas, restando apenas presunções, sabidamente insuficientes para decretação da condenação. Embora o réu ostente condenações anteriores por tráfico de drogas, tem-se de concreto apenas que, no dia dos fatos, foram apreendidas 05 pedras de crack e 02 porções de maconha. A quantidade apreendida com o réu condiz com a figura do porte para uso próprio. Somente suspeitas de que o réu estaria envolvido com o comércio/transporte de drogas para a venda não bastam para ensejar um decreto condenatório. Certamente, causa estranheza o encontro de quantidade significativa de dinheiro, além da atitude de tentar se livrar do próprio celular. Apesar disso, o laudo pericial realizado no aparelho nada trouxe de relevante quanto à eventual transporte de drogas para venda (fls. 228/234).

Não bastasse isso, a testemunha e o informante declararam que o réu é usuário de drogas. Há que se destacar, também, que os próprios policiais não descartaram que o réu teria utilizado drogas naquele dia, justamente em função do seu comportamento alterado no decorrer da abordagem. Assim, reitera-se, é possível que o réu, efetivamente, estivesse comercializando drogas. Porém, quanto aos fatos narrados e apurados nesse processo, há relevantes dúvidas, que devem ser resolvidas em seu favor.

Deste modo, a somatória de todos os elementos de prova existentes não traz a certeza necessária e inafastável para condenação por tráfico, delito de extrema gravidade e de consequências sociais e penais muito severas. A dúvida deve prevalecer em favor do réu. Nesse contexto, não havendo prova contundente de que ele possuía drogas com a finalidade de venda, a providência mais acertada é a desclassificação do delito para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

TRÁFICO DE DROGAS - Prática da traficância que não restou demonstrada pela prova acusatória - Hipótese - Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Possibilidade - Prestação de serviços à comunidade - Réu reincidente - Aplicação da detração analógica - Apelo defensivo parcialmente provido. Prejudicado o apelo Ministerial.

(TJSP; Apelação Criminal 0000317-42.2016.8.26.0291; Relator (a): Ivo de Almeida; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaboticabal - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2017; Data de Registro: 08/03/2017)

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUSENTES EVIDÊNCIAS INEQUÍVOCAS DE MERCÂNCIA POSSIBILIDADE. Cabível a desclassificação para o crime de posse de tóxicos para uso próprio quando as provas colhidas são frágeis a ensejar condenação por tráfico. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICIALIDADE PARCIAL. Ante a desclassificação operada em favor dos réus, fica prejudicado o apelo ministerial no tocante à majoração das reprimendas aplicadas. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO EFEITO SECUNDÁRIO DA PENA APLICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE MOTOCICLETA UTILIZADA APENAS PARA O DESLOCAMENTO DO RÉU NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO INSTRUMENTO DE CRIME PARA OS FINS PREVISTOS NO INCISO III DO ART. 92 DO CP. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO EM PARTE E NEGADO EM PARTE. (Apelação 3005265-16.2013.8.26.0344, Relator Willian Campos, j. 28.01.2016, Dje 01.02.2016).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r. sentença que reconheceu a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário. Mercancia não demonstrada. Conjunto probatório que enseja a desclassificação do delito para o de porte de drogas destinado a consumo próprio, previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. Readequação da pena. Prescrição verificada entre o presente julgamento e a publicação da r. sentença condenatória. Inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal e do artigo 30, da Lei 11.343/2006. RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O DELITO PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E DECLARAR

EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. (TJSP; Apelação Criminal 9001863-57.2009.8.26.0506; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016)

Assim, considerando que à hipótese se aplica o quanto disposto no artigo 383 do CPP (emendatio libelli), uma vez que o acusado foi processado por fatos não alterados pela prova dos autos, ocorrendo apenas nova definição jurídica do delito, prudente o imediato julgamento do feito, sendo dispensável nova abertura da dilação probatória. Daí porque mais razoável, no presente caso, a alteração da definição jurídica do fato para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, porque, na dúvida decorrente do conjunto probatório, deve prevalecer a conclusão mais benéfica ao réu.

Destarte, mais adequada ao caso dos autos a nova definição jurídica da conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06.

Verifico que o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, pois possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, anterior à data dos fatos (fls. 220/224). Reconheço, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea. Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, o acusado é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, pelo que fixo a pena base em advertência.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compenso-as e mantenho a pena no patamar fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena no patamar fixado. Assim, aplico-lhe a sanção definitiva de ADVERTÊNCIA.

Em que pese a reincidência e a presença de maus antecedentes, considero que a advertência é suficiente ao caso, diante da postura colaborativa adotada pelo réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para ABSOLVER JOÃO VITOR SOARES DA SILVA, portador do R.G. n.º 49.708.180, filho de José Galdino da Silva Filho e Cleusa Rocha Soares da Silva, nascido em 13/04/1994 das sanções do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, desclassificando o delito para CONDENAR o acusado JOÃO VITOR SOARES DA SILVA à pena de ADVERTÊNCIA, como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade de justiça, que ora defiro.

Ausentes os requisitos da custódia cautelar, bem como sendo vedada a prisão em decorrência da prática do crime de uso de entorpecentes, o réu poderá recorrer em liberdade. Assim, expeça-se alvará de soltura clausulado, liberando se o acusado JOÃO VITOR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

Caso ainda não se tenha procedido na forma do artigo 50-A da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, inclusive das amostras guardadas (artigo 72, Lei 11.343/06).

Em que pese a desclassificação do delito para o artigo 28, da Lei de drogas, trata-se de situação peculiar, que autoriza a decretação do perdimento dos valores em favor da União. Deveras, embora o réu não tenha confirmado que o dinheiro era oriundo do comércio ilícito de entorpecentes, é certo que declarou sua origem ilícita, decorrente de caça níqueis, o que configura a contravenção penal prevista no artigo 50, do Decreto-lei 3688/41 (Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele). Não há que se falar em revogação tácita da contravenção pelo princípio da adequação social. Nesse sentido:

Jogo de Azar – Provas Suficientes – recurso do Ministério Público provido para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) dias-multa, por incurso no artigo 50 da Lei das Contravenções Penais. (TJSP; Apelação Criminal 1500103-56.2021.8.26.0596; Relator (a): Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira; Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal; Foro de Serrana - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022)

Como trânsito em julgado, determino o perdimento dos valores apreendidos em favor da União.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o instrumental necessário para o integral cumprimento da decisão e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

6. Na sequência, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que requeiro vista para apresentação das razões de apelação. O ACUSADO E SEU DEFENSOR DECLARARAM EXPRESSAMENTE QUE RENUNCIAVAM AO PRAZO PARA RECORRER. A Meritíssima Juíza deliberou: "Certifique-se o trânsito em julgado para a Defesa e encaminhe os autos com vistas ao Ministério Público.

7. PUBLICADO EM AUDIÊNCIA. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS. SERVIRÁ A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO/OFÍCIO. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. José Bonifácio, 06 de outubro de 2022. Eu, Augusto César Cristal Lopes, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Meritíssima. Juíza - Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.